

114年公務人員特種考試司法官考試第二試
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：民法與民事訴訟法(二)

第一題

【總題說明】

本題分為三個子題，(一)在測試於第二審為訴變更之要件為何，以及合法變更後第一審判決所受影響；(二)在測試依民法第425條之1規定之推定租賃關係請求給付租金是否應先請求法院核定其租金額，以及法院對此應如何盡其闡明義務；(三)則在測試原告於法院就本案請求為終局判決後撤回其訴者，得否再提同一之訴。各子題於學說或實務上有不同見解時，考生須分別加以檢討，並提出其所認妥適見解。

【評分要點】

第(一)子題

- 1、甲在第二審將原拆屋還地之請求變更為給付租金之請求，須符合民訴法第446條第1項所定要件，始為合法。除經乙同意外，要判斷兩請求之基礎事實是否同一，或因情勢變更，非以新聲明代原聲明不可。
- 2、第二審訴之變更合法者，原訴視為撤回。因其訴訟繫屬消滅，故第一審法院對之所為判決失其效力。

第(二)子題

- 1、依民法第425條之1規定，推定租賃關係請求給付租金，其租金額當事人不能協議者，得請求法院核定之(同條2項)。在法院核定前，承租人無從給付，出租人亦不得請求。因此，法院不得未經甲聲明核定租金額，即逕自核定而命乙給付之。
- 2、法院應表明上述法律見解，曉諭甲為核定租金額之聲明，以資適法請求給付租金。

第(三)子題

依民訴法第263條第2項規定，於本案經終局判決後將訴撤回者，不得復

提起同一之訴。甲對乙之拆屋還地請求，於第二審為訴變更後視為撤回該訴。甲在給付租金請求經判決確定後，又對乙請求拆屋還地，係就同一事件再行起訴，違反上開規定而不合法。

【閱卷委員的話】

本題有三個子題，第(一)子題與第(三)子題有所關連，均涉及訴之變更後，原訴是否仍為訴訟繫屬，法院是否應為裁判；如發生撤回訴訟之效力，得否再行起訴。

關於第(一)子題，首先應依民訴法第 446 條第 1 項但書規定，就題目之事實判斷是否該當於民訴法第 255 條第 1 項第 2 款至第 6 款規定之事由，尤其是第 2 款規定。考生多數均能回答第 2 款之判斷標準為「變更之訴，就原請求之事實及證據資料，於審理變更之訴得加以利用，使先後兩請求在同一程序得加以解決，俾符訴訟經濟」，甲雖變更請求為給付租金，但其所主張之事實仍係乙有繼續占有之事實，請求之基礎事實同一，並依原審判決所認定之租賃關係請求給付租金，故符合第 2 款規定之事由。如能再就第 4 款或其他事由進行討論，則酌予加分。關於訴之變更是否發生原訴撤回之效力，考生亦多能正確回答，然於第二審為訴之撤回，原第一審判決之效力是否繼續存在，則許多考生答錯，未正確回答第一審判決因原訴之訴訟繫屬消滅，視為未起訴，而失其效力，以致於未獲高分。

第(二)子題涉及法院闡明之義務，多數考生均能回答，基於處分權主義，法院不得逕行判決命乙給付租金予甲，而應就甲不完足之聲明，為適度之闡明。依民法第 425 條之 1 規定，當事人於協議不成時，應先向法院請求酌定，此為形成之訴，而於法院尚未酌定租金之數額前，原告尚無從為具體租金數額之給付請求，如逕為請求給付租金，則欠缺一貫性，故原告之聲明並不適當，法院應依民訴法第 199 條第 2 項規定闡明原告，是否因未能協議，而請求法院酌定租金數額；如原告未請求法院酌定租金，則法院不得逕命給付租金。

第(三)子題涉及民訴法第 263 條第 2 項規定：「於本案經終局判決後將訴撤回者，不得復提起同一之訴」，多數考生忽略此規定，以致於本題完全答錯，未能獲得理想分數。其次，許多考生亦未注意前訴訟已為訴之變更及訴之撤回效力，而誤認前訴訟之判決係以民法第 767 條第 1 項規定所有物返還請求權為訴訟標的，故回答後訴訟之訴訟標的已受前訴訟之確定判決效力所及，而不得再行

起訴，以致於論述上有所錯誤。本題應先回答前訴訟中發生訴撤回效力之該訴，其訴訟標的為何，是否與後訴之訴訟標的相同，亦即，甲於該二訴所主張之法律（請求權）基礎與原因事實均相同，甲於後訴訟所陳稱「甲、乙間原分管協議已因分割 A 地之判決確定而消滅」等語，不過係攻擊方法之補充而已，故二者之訴訟標的相同，後訴訟因受民訴法第 263 條第 2 項規定之限制，不得再提起，後訴訟為不合法（民訴法第 249 條第 1 項第 7 款）。

第二題

【總題說明】

本題分為三個子題，（一）在測試考生對於原告甲依民法第 242 條規定，對債務人乙之債務人丙（第三債務人）提起代位訴訟時，其訴之聲明應如何記載；及於甲記載聲明有誤時，法院應如何處理。（二）在測試考生對於甲不具備代位資格（即對乙無債權存在）時，法院應如何就該代位訴訟為判決；及甲得否再以乙為被告，另行起訴請求乙清償債務。（三）在測試考生有關丁（轉包承攬人）之動產與丙之房屋附合時權利歸屬之理解；及丁可否請求丙返還不當得利。

【評分要點】

第（一）子題

1. 代位訴訟之聲明應包括命被告（第三債務人）丙向債務人乙為給付，而由債權人甲代位受領，不得逕命對甲給付。另須說明代位訴訟之本質。
2. 原告之聲明如與民法第 242 條規定之代位要件及權利實際歸屬不合，法院應先闡明，使甲有機會變更或更正，不得未經闡明即以駁回。另須說明法院闡明權行使之必要性及界限。

第（二）子題

1. 如甲非乙之債權人，即無代位權，所提起之代位訴訟欠缺當事人適格，應依民訴法第 249 條第 2 項第 1 款規定，以訴訟判決駁回之。並須說明代位權之取得乃法定訴訟擔當之一種，及何以該當於當事人適格欠缺而非前訴無理由之相關法理。
2. 前後兩訴當事人、訴訟標的均不同，非同一事件，且前訴判決為訴訟判決，對未參與前訴之乙無既判力亦無爭點效，甲得再行起訴。並須說明發生既判

力之前提為程序權保障，唯有經裁判之訴訟標的始有既判力。前訴乙未曾參與，在甲、乙間不存在經裁判之訴訟標的，亦無爭點效可言。

第(三)子題

丁提供之材料已因附合而成為丙所有房屋之重要成分，依民法第 811 條規定，由丙取得該材料之所有權。然而，丁提供該材料附合於丙所有之房屋，係丁基於契約關係對乙所為之給付，同時亦為乙基於契約關係對丙所為之給付，基於債之相對性，為維護給付關係當事人間之信賴與抗辯，財產上損益變動是否不當，應優先適用當事人間之契約關係，丁不得依民法第 816 條規定直接向丙請求償還價額。

【閱卷委員的話】

第(一)子題

本子題在測驗考生對於民法第 242 條規定之代位權行使，於民事訴訟程序之起訴聲明應如何主張，又如訴之聲明有所不當時，法院應依職權而依民事訴訟法第 199 條第 1 項及第 2 項規定行使闡明權之認識。

有關債權人代位權，民法第 242 條定有明文。該條規定，債務人怠於行使其權利時，債權人因保全債權，得以自己之名義，行使其權利。但專屬於債務人本身者，不在此限。本規定所稱「債權人因保全債權，得以自己之名義，行使其權利」於民事訴訟應如何主張，訴之聲明應如何展現？實務上認為，債權人代位債務人起訴請求給付者，須聲明被告（第三債務人）應向債務人為給付之旨，並就代位受領為適當之表明，始與代位權行使之要件及其效果之法理相符（最高法院 64 年台上字第 2916 號裁判先例、最高法院 94 年度台上字第 1193 號判決參照）。因而，本題債權人（甲）行使代位權之訴之聲明應為：「丙應給付乙 200 萬元，由甲代位受領」。就此部分解題，許多考生能正確闡述。又於民事訴訟中訴之聲明提起，如有不明瞭或不完整者，審判長依民事訴訟法第 199 條第 1 項、第 2 項規定，應向當事人闡明，使其就訴訟關係所涉法律觀點，為必要之陳述及適當完全之辯論。因此，法院為保障當事人之聽審請求權、辯論權，並貫徹防止突襲性裁判之要求。於本題中，甲之訴之聲明並不正確，但法官就聲明部分應為適度闡明，促使甲有機會變更或更正其訴之聲明，不得於未經闡明即以判決駁回其訴。於本次考試中，多數考生對於闡明權之適用，亦能正確寫出。

就考生答題之內容，本子題對於用心學習法律之考生而言，試題難易適中，並不艱澀，考生於本子題之成績並不差。

第(二)子題

本子題在測驗考生之重點有二，第一：對於欠缺當事人適格之訴訟，法院應如何審理該訴訟？第二：當債權人提起代位訴訟，如法院認定債權人所主張對債務人之債權並不存在，因而以決駁回其訴時，債權人對債務人得否另行起訴？

第一，債權人提起代位訴訟，就當事人適格之問題，相較於第(一)子題，考生於本子題之解題成績稍弱。民法第 242 條規定之代位權，係債權人代行債務人之權利，故代行者與被代行者之間，必須有債權債務關係之存在，否則即無行使代位權之可言（最高法院 49 年台上字第 1274 號裁判先例參照）。因而，本子題之甲主張其身為乙的債權人而代位行使債務人對第三人(丙)之權利，然如受訴法院調查結果發現，乙業已清償對甲之該借款債務時，甲已非乙之債權人，則甲提起代位訴訟並不符合民法第 242 條規定代位權之要件。因而，甲提起代位訴訟因欠缺當事人適格，法院應依民事訴訟法第 249 條第 2 項第 1 款規定，以訴訟判決駁回其訴。

第二，考生於本部分之答題，可以清晰回答的比例又較本子題前面當事人適格之問題為低，不少考生認為不得另行起訴。當受訴法院以甲已非乙之債權人為理由，而依民事訴訟法第 249 條第 2 項第 1 款規定，以訴訟判決駁回其訴確定後，甲得否另對乙提起請求返還該借款之訴訟？債權人依民法第 242 條及第 243 條規定，提起代位訴訟，其訴訟標的為債務人對第三債務人之權利，債權人之代位權在訴訟程序中為當事人適格之要件，非為訴訟標的法律關係本身（最高法院 73 年度台上字第 329 號判決要旨參照），其對於甲乙間之系爭借款請求權，依民事訴訟法第 400 條規定，不生既判力。因而，甲於前開判決確定後，得另行起訴請求乙返還借款，蓋前後兩訴之當事人及訴訟標的均不相同，請求返還借款之訴訟非前開確定判決之效力所及。

第(三)子題

本子題在測驗考生對債權性質之認識。民法第 816 條規定，因前五條之規定而受損害者，得依關於不當得利之規定，請求償還價額。本子題，丁提供之材料已因附合而成為丙所有房屋之重要成分，依民法第 811 條規定，由丙取得該材料之所有權。乍看之下，民法第 816 條規定，丁得依民法第 816 條規定直接向

丙請求償還價額。然而，丁提供該材料附合於丙所有之房屋，係丁基於契約關係對乙所為之給付，同時亦為乙基於契約關係對丙所為之給付，基於債之相對性，為維護給付關係當事人間之信賴與抗辯，財產上損益變動是否不當，應優先適用當事人間之契約關係，丁不得依民法第 816 條規定直接向丙請求償還價額。許多考生於本子題解答，未注意到乙承攬丙工程之關係，因而未思考到乙對丙之給付關係，因而未能正確解題。本題，由於丁對丙並無給付關係，然乙對丙有給付關係，且依給付優先原則，丁不得依民法第 816 條關於不當得利之規定向丙請求償還該材料之價額。

整體而言，本題考試爭點為民法債編與民事訴訟法之重要基本概念，考生普遍成績為中等以上，並且許多考生答題內容表現傑出。